

1500799-17.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... até a sexta série; já foi processado por tráfico, tendo sido condenado e cumprido as penas de todos (fls. 167/168).

A testemunha Douglas Rodrigues Gonçalves, policial militar, ouvido às fls. 167/168, disse que estava em patrulhamento no Bairro Santa Clara, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistou o réu, que estava com uma sacola na mão, e saiu correndo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500799-17.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500799-17.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO LUIS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

FLÁVIO LUIS DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 04 de agosto de 2022, por volta das 19h50min, na Rua Um, nº 239, Bairro Santa Clara, nesta cidade e Comarca de Atibaia, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, drogas, consistentes em 5 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, peso bruto de 62g, 406 porções de crack, peso bruto de 266g, e 2 porções de cocaína, peso bruto de 8g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento pelo local acima mencionado, conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando se depararam com o réu em poder de uma sacola, o qual tentou empreender fuga ao avistar a viatura policial.

Os policiais conseguiram abordá-lo e, em seu poder, encontraram as drogas acima descritas no interior da referida sacola, além de R\$181,00 em dinheiro. FLÁVIO confessou informalmente aos policiais que estava no local realizando o tráfico de drogas.

Ainda segundo consta, evidente, pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pelo numerário apreendido, que as substâncias pertenciam ao réu e se destinavam ao comércio ilícito.

O flagrante foi convertido em preventiva às fls. 46/48.

O réu foi notificado (fls. 101), e apresentou defesa prévia (fls. 109/110), que foi afastada, sendo recebida a denúncia (fls. 121/124).

O réu foi citado (fls. 166).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado ao final (fls. 167/168).

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal porque provados os fatos narrados na denúncia (fls. 171/180).

A defesa requereu a improcedência da ação, com a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; o laudo de fls. 155 aponta a quantidade de 19 gramas de maconha, o que vai de encontro aos depoimentos dos policiais; subsidiariamente, em caso de condenação, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, postulando, por fim, a expedição de alvará de soltura em favor do réu (fls. 184/186).

É o relatório.

Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 11), no boletim de ocorrência (fls. 11/13), no auto de exibição/apreensão (fls. 14/15), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 16/17), nas fotografias (fls. 18/20), nos laudos toxicológicos (fls. 89/91, 92/94 e 154/156), e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada ao réu que, interrogado extrajudicialmente, não teve condições de exercer sua autodefesa, tendo em vista que se encontrava "visivelmente alterado e agressivo" (fls. 07).

Em juízo, interrogado, negou os fatos. Disse que mora no Jerônimo I, sendo que foi até o local dos fatos pois seu sobrinho estava com dor de dente; questionado se confessa ou nega o tráfico, disse que não reconhece nada; questionado sobre as drogas e o dinheiro que foram encontrados consigo, disse que trabalha das oito horas da manhã até as seis da tarde, como eletricitista; estava trabalhando na "treze", ao lado do Fórum do Alvinópolis, e cortou seu dedo, sendo que tudo foi filmado; ia receber seu pagamento no dia seguinte, sendo que não tinha dinheiro nenhum; foi almoçar, e não tinha "mistura" na sua marmita, sendo que usou o dinheiro que sua mãe deu, para comprar uma marmita; foi até o Picanha na Tábua e perguntou à funcionária quanto custava um pedaço de carne, ao que ela respondeu que custava R\$ 18,00, sendo que só tinha R\$ 14,00, então perguntou se ela não vendia mais barato, tendo a funcionária respondido que não, então pegou um guaraná, e voltou para o seu serviço, comeu, tomou seu guaraná e trabalhou, tendo cortado o dedo, o que foi filmado; às seis horas da tarde, acabou o trabalho e foi embora; ao chegar na sua casa, seu sobrinho estava com a boca inchada, precisando de remédio; não tinha dinheiro, e discutiu com sua mãe e sua irmã, por causa do seu sobrinho, sendo que a única solução era avisar o pai do menino, que morava na Rua Um, então pegou sua bicicleta e foi até o local; parou na frente da casa do seu cunhado e o chamou, ocasião em que viu os policiais "enquadrando" um rapaz; chamou seu cunhado, mas ninguém atendeu, então subiu a rua, em direção aos policiais, para ir embora; quando estava indo com a bicicleta, foi parado pelo policial, que questionou onde estava a droga, ao que respondeu perguntando a que droga ele se referia; o policial mandou jogar a bicicleta, o que obedeceu, tendo o policial perguntado se mora no Jerônimo I, ao que respondeu positivamente; o policial questionou o que aconteceria se fosse até o local e encontrasse drogas, ao que respondeu que ele podia ir consigo, então o policial perguntou se tinha

anteriores, ao que respondeu positivamente; o policial, então, disse que entregaria alguém naquele momento, e questionou se sua liberdade tinha preço, ao que tinha preço, e que ele estava com o poder na mão, e sabia o que faria; o policial disse que o acompanharia até sua casa, e o colocou na viatura, tendo o apresentado na Delegacia; questionado se não tinha nada, não estava fazendo nada, não dispensou nada, e os policiais saíram nesse dia, com a intenção de prejudicá-lo, disse que não sabe, sendo que viu os policiais soltando um rapaz; questionado de onde saíram as drogas, disse que não sabe; trabalha como eletricitista, e tinha renda mensal de R\$ 1.500,00; estudou até a sexta série; já foi processado por tráfico, tendo sido condenado e cumprido as penas de todos (fls. 167/168).

A testemunha Douglas Rodrigues Gonçalves, policial militar, ouvido às fls. 167/168, disse que estava em patrulhamento no Bairro Santa Clara, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistou o réu, que estava com uma sacola na mão, e saiu correndo ao se deparar com a viatura, então perseguiu o réu e realizou a abordagem; na sacola havia maconha, crack e cocaína, drogas que estavam embaladas para a comercialização; no shorts do réu havia uma quantia em dinheiro, em notas trocadas, sendo aproximadamente R\$ 180,00; diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao réu, que foi conduzido à Delegacia; questionado o que o réu disse quando foi abordado e foram encontradas as drogas, bem como o dinheiro, disse que a princípio, ele falou que era vendedor, e atuava como "vapor", sendo que, posteriormente, na Delegacia, FLÁVIO negou os fatos; questionado se o réu aparentava que tinha ingerido alguma substância, disse que não; questionado sobre ter constatado que o réu não foi interrogado na Delegacia, pois estava muito alterado, disse que o réu estava ameaçando os policiais, sendo que ele não o ameaçou, mas ameaçou seu parceiro, tendo dito que, se ficasse preso por mais de dez anos, conseguiria uma arma e o mataria; questionado se a alteração não era em decorrência do uso de alguma substância, e sim pelas ameaças, em razão de irritação e nervosismo, disse que sim.

A testemunha Lucas Lozardo Cavalcante, policial militar, ouvido às fls. 167/168, disse que estava em patrulhamento de força tática no município de Atibaia, no Bairro Santa Clara, quando visualizou FLÁVIO, levando uma sacola na mão, tendo o réu empreendido fuga ao avistar a viatura policial, sendo abordado alguns metros à frente; feita a abordagem, foi constatado que, no interior da sacola, havia drogas, consistentes em 406 tubos de crack, 5 tubos de maconha, e 2 eppendorfs de cocaína, sendo que, no bolso do shorts do réu, havia R\$ 181,00 em cédulas e moedas diversas; indagado, o réu admitiu que estava traficando, e que fugiu pois estava com medo de ser preso; questionado se o réu estava alterado na Delegacia, disse que estava; questionado o que aconteceu, disse que o réu estava gritando e xingando todos, inclusive os policiais civis; às reperguntas da defesa, questionado o que o réu falou quando foi abordado, disse que ele só falou que estava traficando, tendo utilizado o jargão "a casa caiu", e não quis falar mais nada.

Assim, os fatos estão plenamente comprovados.

O réu, em fase policial, não foi ouvido, uma vez que estava visivelmente alterado, sendo que, em juízo, negou os fatos, alegando, em síntese, que não sabe de onde saíram as drogas, e que foi até a casa do seu cunhado, uma vez que seu sobrinho estava com dor de dente, e não tinha dinheiro para comprar remédios para ele.

Disse, também, que os policiais, que estavam abordando um rapaz, também o abordaram, e questionaram onde estava a droga, ao que respondeu questionando a que droga eles se referiam, tendo os policiais o colocado na viatura e o apresentado na Delegacia.

Logicamente, a versão do réu é absolutamente fantasiosa, e não merece qualquer credibilidade, restando claro o objetivo de se eximir da responsabilidade pelos fatos criminosos, tendo sido infirmada pelas demais provas trazidas aos autos.

Senão, vejamos:

Os policiais, cujos depoimentos se mostraram firmes e coerentes, narraram, em síntese, que estava em patrulhamento por local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o réu, que levava uma sacola na mão, e empreendeu fuga ao perceber a presença da viatura. Disseram, também, que o réu foi abordado e, dentro da sacola, foram encontradas drogas, consistentes em maconha, crack e cocaína,

tendo sido encontrada, no bolso do réu, a quantia de R\$ 181,00, em notas trocadas. Disseram, ainda, que o réu, ao ser abordado, admitiu que estava traficando, tendo o policial Douglas narrado que FLÁVIO disse que atuava como "vapor", no entanto, em solo policial, o réu negou os fatos. O policial Douglas narrou, ainda, que FLÁVIO ameaçou os policiais na Delegacia, tendo o réu dito a um dos agentes da lei que, se ficasse preso por mais de dez anos, conseguiria uma arma e o mataria. O policial Lucas narrou, também, que FLÁVIO, na Delegacia, estava gritando e xingando todos, inclusive os policiais civis.

Quanto aos policiais, há de se lembrar que seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais ou das forças de segurança, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto, absurdo, de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos, judiciais que sejam prestados por policiais, sejam civis ou militares, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Não. Inexiste qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de policiais, civis ou militares, de resto, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retirasse valor, "a priori", dos depoimentos policiais, pelo simples fato de terem sido emanados por pessoas revestidas de tal qualidade. Nesse sentido, por sinal, a melhor jurisprudência: "A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF-HC 70.237- Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94); "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por isso, força convir, os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em Juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os depoimentos prestados extrajudicialmente, policiais que não tinham, mesmo, qualquer interesse maior na gratuita acusação do réu.

Assim, verifica-se que a versão do réu é absolutamente inconsistente, tendo sido infirmada por todo o restante da prova produzida. E embora tenha alegado que foi até o local dos fatos apenas para falar com seu cunhado, supostamente por causa do seu sobrinho, que estava sentindo dores e precisava de remédios, para os quais supostamente não tinha dinheiro, o réu não soube explicar por que foi preso em posse de R\$ 181,00 (em notas trocadas, diga-se). Ademais, FLÁVIO também não produziu qualquer prova de sua versão, que restou isolada, como dito. Por fim, o réu também não soube explicar por qual motivo foi preso com elevadíssima quantidade de drogas, consistentes em 406 porções de crack, 5 porções de maconha e 2 porções de cocaína.

Outrossim, embora a defesa tenha alegado, em seus memoriais, que há contradição entre os depoimentos dos policiais e o laudo pericial de fls. 155, observo que três foram os laudos toxicológicos juntados aos autos (fls. 89/91, 92/94 e 154/156), que constatarem as drogas em quantidades equivalentes às que os policiais narraram, não havendo, portanto, qualquer contradição.

Assim, toda a prova produzida foi plenamente apta a comprovar que FLÁVIO estava mesmo na traficância, de modo que sua conduta se amolda perfeitamente à descrição

do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo a condenação medida que se impõe. Por isso, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal. No entanto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu é duplamente reincidente específico, conforme se verifica às fls. 38/41 e 42/45. Considerarei como maus antecedentes o proc. 3006730-75.2013 (fls. 44/45 - tráfico), sendo a outra reincidência considerada como agravante.

Não há que se falar em bis in idem na consideração da reincidência e dos maus antecedentes, porque como já se decidiu, se o réu for duplamente reincidente, uma das circunstâncias pode ser considerada como agravante e a outra, como circunstância judicial para aumento da pena-base (TACRIM, Acir 455.109, 8ª Câmara, em 18-12-99, rel. Silva Pinto).

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. MESMA CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSIDERADA DUAS VEZES. FASES DISTINTAS DE APLICAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. JUÍZO NEGATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. (...) 4. É pacífica a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo. 5. Este Sodalício orienta que não configura bis in idem ou inconstitucionalidade, quando, reconhecidas múltiplas reincidências, o sopesamento, na fixação da condenação, de uma na primeira fase, para exasperar a pena-base pelos maus antecedentes (art. 59, CP), e de outra na segunda fase, como circunstância agravante (art. 63, CP) (...)" (STJ - HC: 215126 MS 2011/0183443-9, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2013) (destaquei).

Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar. Quanto à sua conduta social, lamentável. Conforme narrou o policial Douglas, o réu, na Delegacia, proferiu ameaças contra os policiais, tendo dito a um deles que o mataria, caso ficasse preso por mais de dez anos. O policial Lucas, por sua vez, narrou que FLÁVIO gritava e xingava os policiais. Evidente, portanto, o completo desprezo do réu pelas leis e pelo convívio em sociedade, merecendo, portanto, maior reprimenda. Quanto aos motivos do crime, nada capaz de ensejar modificação de pena. As consequências do crime são as normais ao tráfico. Não há que se falar em comportamento de vítimas.

Quanto à natureza e quantidade do produto, foi encontrada, em posse do réu, considerável quantidade de drogas, totalizando 406 porções de crack, 5 porções de maconha e 2 porções de cocaína, o que merece maior reprovação.

O crack é um dos entorpecentes mais perigosos conhecidos, gerador dos efeitos mais nefastos em seus usuários. A alta taxa de mortalidade entre os consumidores e o absurdo poder viciante do entorpecente são motivos mais que suficientes para que seja, sua comercialização, exemplarmente repreendida, especialmente considerando a elevadíssima quantidade que o réu levava consigo, apta a atender vasta clientela (artigo 42, Lei 11.343/06).

Sobre o tema, pronunciou-se Guilherme de Souza Nucci: "(...) não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos também constantes do art. 59 do Código Penal (...) A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na

punição de crimes de perigo abstrato, o que significa destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas 6ª ed. - São Paulo: RT 2012 v. 1 p. 287).

Assim, em razão dos maus antecedentes, da conduta social do réu e da natureza, quantidade e grau de nocividade das drogas apreendidas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, 07 anos e 06 meses de reclusão, e 750 dias-multa, diária mínima, uma vez que o réu está preso, portanto, sem renda.

Na segunda fase de dosimetria, há a agravante da reincidência, conforme se verifica às fls. 42/43 (proc. 196-57.2018 - tráfico), não havendo atenuantes.

Assim, agravo a pena do réu, que passa a 08 anos e 09 meses de reclusão, e 875 dias-multa.

Na última fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Evidentemente incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. O réu é duplamente reincidente específico, sendo evidente que se dedica às atividades criminosas, não preenchendo, portanto, os requisitos exigidos no parágrafo quarto.

Ficam vedados, ainda, pelas mesmas razões, quaisquer outros benefícios, incluindo-se a substituição da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, por não preencher os requisitos legais.

O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado.

O tráfico de entorpecentes é das atividades mais danosas ante o seio social hodierno. Sua prática atinge diretamente direitos e garantias fundamentais das pessoas, além de fomentar outros tipos de atividades ilícitas. Causa, ainda, direta e indiretamente, considerável mobilização estatal, atingindo, por consequência, o erário público, que tem de arcar com as custas de policiamento ostensivo, seja preventivo ou repressivo, campanhas de conscientização - sobre o óbvio, diga-se -, tratamento de saúde aos adeptos do uso contumaz, dentre outras inúmeras situações relacionadas, as quais requerem pronta ação do Estado. Isto, entretanto, custa dinheiro e onera o contribuinte.

Seria um contrassenso o mesmo Estado que luta para combater tão nefasta prática - a tão altos custos - permitir que seu principal responsável retorne à liberdade sem experimentar a necessária punição e, principalmente, sem que de seu ato se arrependa, sobre ele reflita e o corrija, podendo criar, em última análise, a aplicação de regime mais brando, verdadeira sensação de impunidade, capaz, inclusive, de ensinar ao condenado mais um motivo para que torne à rentável prática.

Nem se diga haver o pequeno traficante, sobre quem recairia todo o peso da mão Estatal, e o grande traficante, que se ocultaria na hierarquia da coalizão narcotraficante, como tentativa de justificar atos injustificáveis. A Lei coíbe o tráfico e este existe por duas razões: porque alguém consome o produto final e, principalmente, porque alguém o vende - eis a figura daquele que trafica, independentemente de sua posição hierárquica.

A ação do indivíduo encarregado de disseminar a substância entorpecente - geralmente identificado como o "pequeno traficante" - deve ser entendida como parte integrante e crucial do conjunto responsável pela narcotraficância: é ele que, por meio de sua ação, viabiliza o comércio "varejista" das drogas, fomentando o consumo e a própria continuidade da produção de entorpecentes, consubstanciando, sua atividade, não só o meio de sustento próprio, mas de toda a cadeia criminosa ligada ao narcotráfico - prática delitiva que domina a maior parte dos debates sobre segurança pública e que consiste, em verdade, no cerne financeiro das atividades criminosas em geral.

É do espírito da Lei combater o tráfico ilícito de entorpecentes, seja ele praticado pelo iniciante - a quem é conferido algum tipo de benefício, conforme se observa do parágrafo 4º do artigo 33, Lei 11.343/06 - pelo gerente de "boca" ou por associados a organizações criminosas - pessoas a quem a Lei trata de maneira

especial e mais severa.

O fato é que o tráfico, independentemente do tipo de atuação de seu praticante, merece reprimenda exemplar.

Sobre todo o tema até então debatido, uma brilhante manifestação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“(...) Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e a recente decisão da Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de direitos” constantes dos artigos 33, § 4º e 44 da Lei Antidrogas. Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na decisão é ressaltada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição. Tal como veiculado de forma contínua nos diários de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião; o comércio ilegal avança de forma incontornável, ora favorecido pela insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal. Evidentemente o grande traficante, o responsável pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de necessidades básicas. Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O número expressivo de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas, bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena por quaisquer das medidas alternativas. Portanto, acolho a pretensão do representante do Ministério Público e fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista que se trata do regime compatível com a conduta do acusado. Cumpre ressaltar ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir, data máxima vênua, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um revés de complexidade. Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal? Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante? A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante. Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas. E a consequência desta fartura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênua, que de algum tempo

a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua sobrevivência. Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano. Devo reconhecer que tenho sido voto vencido junto a meus pares, a cujos posicionamentos me curvo com a humildade esperada, e por isso mesmo, eventualmente, sou reconhecido como extremamente rigoroso, entretanto, não o faço como castigo, o que seria de todo despropositado e bem acarretaria o desvirtuamento da finalidade da pena. É imperativo ressaltar também que não tenho a menor intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes - como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na Lei nº 11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria visualizar a figura do pequeno traficante. (...)” (APL TJ-SP 0027320-18.2012.8.26.0224; Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Publicação: 18/01/2017; Julgamento: 14 de Dezembro de 2016; Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro).

Salutar a fundamentação, que reduz a termo o espírito buscado pela construção normativa do Legislador. É razão mais que suficiente para que se entenda que o praticante do tráfico de drogas deve permanecer afastado do convívio em sociedade, especialmente considerando que, repito, trata-se de réu duplamente reincidente específico.

Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno FLÁVIO LUIS DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, regime fechado e multa de 875 dias-multa, diária mínima, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

O réu está preso e assim deverá permanecer, já que foi preso em flagrante e permaneceu recolhido por todo o processo, não sendo razoável que, agora que foi condenado a alta pena, seja colocado em liberdade, ainda mais diante do fato de ter praticado conduta de extrema gravidade, nos termos acima fundamentados, além de ser duplamente reincidente específico, conforme já relatado acima. A prática exige punição exemplar. Ademais, não há segurança ao juízo de que o réu, uma vez em liberdade, não acabe voltando a praticar o delito que culminou com sua prisão, seja para saldar eventual dívida que ostente com o tráfico, em razão da apreensão das drogas, seja para garantir seu próprio sustento, já que ficou demonstrado que o réu faz do ilícito seu modo de vida. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea “a” da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003. Suspensa, entretanto, a condenação, caso o réu seja beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

P.R.I. e C.

Atibaia, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA